

<입문-제5장 공법행위.제1절 개념 및 종류>

I. 개념

- 공법행위는 공법상의 권리·의무를 발생, 변경, 소멸시키는 행정주체의 법률행위를 의미한다. 이는 사법상의 법률관계 변동을 목적으로 하는 사법행위(민법상의 계약)와 구별된다. 공법행위는 국가 또는 지방자치단체 등의 행정주체가 행하는 행정작용의 핵심을 이루며, 사인 역시 공법상의 권리·의무 변동을 가져오는 행위(행정기관에 대한 신청 또는 신고)를 할 수 있으므로, 행정주체와 사인 모두의 행위를 포함한다. 광의의 공법행위는 행정주체의 법률행위적 행위(행정행위)은 물론, 단순한 사실 행위적 행위(경찰관의 정보 수집)까지 포함하며, 이러한 행위들은 모두 공익을 목적으로 하고 행정법의 규율을 받는다는 특징이 있다. 협의의 공법행위는 주로 공법상의 법률 효과 발생을 의도하는 법률행위적 행위에 한정되어 사용되기도 한다. 행정주체의 공법행위 중 가장 중요한 형태는 일반적으로 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하는 행정행위이다. 공법행위는 그 본질상 공익 실현을 위한 활동이므로, 법률 우위의 원칙 및 법률 유보의 원칙 등 법치주의 원칙의 적용을 받으며, 민법상의 일부 규정(의사표시의 하자에 관한 규정)이 공법의 특성에 맞게 준용되거나 배제된다. 따라서 공법행위의 개념 정의는 각 행위의 법적 효과와 유효성 여부를 판단하는 기본 전제가 된다.

II. 종류

- 공법행위는 행위의 주체, 법적 성질 등에 따라 분류된다. 이러한 분류는 각 행위에 적합한 법적 원칙과 통제 수단을 적용하기 위해 필수적이다.

1. 행위 주체에 따른 분류

- 공법행위를 행하는 주체가 행정주체인지 사인인지에 따라 공법행위의 법적 특성과 효력이 크게 달라진다.

(1) 행정주체의 공법행위

- 국가, 지방자치단체 등의 행정주체가 공익 실현을 위해 행하는 모든 활동을 포함한다. 이 행위는 공권력의 행사 여부에 따라 다시 세분된다. 공권력을 행사하는 경우는 행정행위로 가장 대표적이며, 비권력적 활동의 경우는 행정상 사실 행위, 공법상 계약 등으로 나뉜다. 행정주체의 공법행위는 법률 우위 및 법률 유보의 원칙이 가장 엄격하게 적용되는 영역이다.

(2) 사인의 공법행위

- 사인이 공법상의 권리·의무 변동을 목적으로 행정주체에 대해 행하는 행위를 의미한다. 이는 사인이 공법관계의 당사자로서 자신의 의사를 표시하는 것으로, 행정주체의 작용을 발동시키거나 법적 효과의 발생에 영향을 미친다. 예를 들어 행정기관에 대한 신청(허가 신청, 특허 신청), 공법상의 신고(납세 신고, 영업 신고), 동의, 철회, 청구 등이 이에 해당한다. 사인의 공법행위는 일반적으로 민법상의 의사표시에 관한 규정(착오, 사기, 강박)이 공법의 특성을 고려하여 준용되거나 적용이 배제된다. 특히 신고의 경우, 수리가 필요한 신고인지 여부에 따라 법적 효력 발생 시점과 분쟁 해결 방식이 달라진다.

2. 법적 성질에 따른 분류

- 공법행위가 법률 효과를 직접 목적으로 하는지 여부에 따라 법률행위적 행위와 사실 행위적 행위로 구분되며, 이는 행위의 법적 통제 방식을 결정하는 중요한 기준이 된다.

(1) 법률행위적 공법행위

- 행위자가 공법상의 법적 효과 발생 또는 변동을 직접적으로 의도하고 그에 따라 법적 효과가 발생하는 행위를 말한다. 이러한 행위는 당사자의 의사 표시를 필수 요소로 한다.

① 행정행위

- 행정주체가 법 아래에서 구체적 사실에 대하여 공권력의 주체로서 일방적으로 행하는 법 행위로서, 국민의 권리·의무에 직접 변동을 초래하는 가장 중요하고 전형적인 공법행위이다. 행정행위는 명령적 행위(허가, 하명, 면제)와 형성적 행위(특허, 대리, 인가)로 다시 나뉜다. 예를 들어 과세 처분, 영업 허가, 공무원 임용 등이 대표적이며, 공정력, 집행력, 불가쟁력 등 특수한 효력이 인정된다.

② 공법상 계약 및 합동 행위

- 공법상 계약은 행정주체가 사인 또는 다른 행정주체와 대등한 지위에서 공익 목적을 위해 체결하는 합의로서, 쌍방의 의사 합치를 요소로 하는 법률행위적 공법행위이다. 예를 들어 공공 시설 위탁 운영 계약, 공무원 채용 계약 등이 있다. 공법상 합동 행위는 다수의 행정주체 또는 사인이 단일한 공익 목적을 위해 같은 방향의 의사 표시를 하는 것을 의미한다.

③ 사인의 법률행위적 공법행위

- 사인의 신고, 신청 등 행위 자체가 법적 효과(신고의 경우 법적 의무의 이행 완료)를 발생시키는 경우를 말한다. 특히 자기완결적 신고는 행정기관의 수리가 없어도 신고서가 도달하는 것만으로 법적 효력이 발생하는 사인의 법률행위적 공법행위로 간주된다.

(2) 사실 행위적 공법행위

- 법적 효과 발생을 직접 목적으로 하지 않고, 단순히 사실적 결과를 가져오는 행위를 말한다. 행정주체가 직접적으로 국민의 권리·의무에 변동을 주지는 않지만, 공익 목적 달성에 필요한 정보 수집, 사실 확인, 서비스 제공 등의 활동이다. 예를 들어 행정지도, 교통 경찰관의 수신호, 공공 정보 제공, 도로 청소 등의 집행 행위 등이 있다. 사실 행위 중 일부는 비록 법률 행위는 아니지만, 사실상의 강제를 수반하거나 국민의 법적 지위에 중대한 영향을 미치는 경우(강제 철거의 실행)에는 예외적으로 항고소송의 대상이 되는 행정 처분으로 인정되기도 한다. 사실 행위는 행정의 재량이 넓게 인정되는 경우가 많지만, 법치주의의 원칙상 위법한 사실 행위에 대해서는 국가 배상 청구 등의 책임이 따를 수 있다.

III. 결론

- 공법행위는 행정주체와 사인의 공법적 활동 전반을 포괄하는 개념이며, 그 종류는 행위 주체에 따라 행정주체의 행위와 사인의 행위로, 법적 성질에 따라 법률행위적 행위와 사실 행위적 행위로 나뉘어진다. 행정행위는 법률행위적 공법행위의 핵심으로서 공정력 등 특수한 법적 효력을 가지는 반면, 사실 행위는 법적 효과가 아닌 사실적 결과를 목표로 한다. 이러한 분류는 각 공법행위에 적용될 법적 통제 원리를 결정하고, 위법한 행위에 대한 국민의 구제 수단을 정립하는 데 있어 행정법상 가장 기초적인 작업이다.